

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. Aが不同意性交された場合、Aの夫は、「犯罪により害を被った者」として告訴権を有する。

(改)

イ. 被害者の法定代理人がした告訴を被害者本人が取り消すことはできない。

ウ. 告訴は、適法に受理された後はこれを取り消すことができない。

エ. 器物損壊罪の被害者が犯人をXと指定して告訴したが、捜査の結果、犯人はYであることが判明した場合、その告訴はYに対して有効である。

オ. 一通の文書でA及びBの名誉が毀損された場合、Aがした告訴の効力は、Bに対する名誉毀損の事実には及ばない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No.35

告 訴

正答率

予備H27-15

正 解

2

65%

ア 誤っている

「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」(230条)。「犯罪により害を被つた者」とは、刑罰法令における各犯罪の構成要件該当行為の予定する被侵害法益の主体を指すと解されている。不同意性交罪においては、不同意性交をされた者がこれに当たる。「犯罪により害を被つた者」は不同意性交されたAであり、Aの夫はこれには当たらない。よって、Aの夫は「犯罪により害を被つた者」には当たらず、告訴権を有しない。なお、被害者が死亡したときは、その配偶者は告訴をすることができる(231条2項本文)が、Aは死亡していないので、Aの夫は、告訴権を有しない。

イ 正しい

「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる」(237条1項)。告訴を取り消すことができるのは、当該告訴をした者であると解されている。告訴権者たる被害者の法定代理人(231条1項)のした告訴を、告訴権者たる被害者本人(230条)が取り消すことができるかについては争いがある。判例は、法定代理人の告訴権はその固有権であるという立場に立っている(最決昭28.5.29)ので、この立場を前提にすると、判例は、法定代理人が告訴した場合における被害者本人の告訴の取消しを否定するものと思われる。

ウ 誤っている

「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる」(237条1項)。告訴の取消しとは、有効に行われた告訴の効果を将来に向かって消滅させる訴訟行為(告訴の撤回)である。告訴が有効に行われ適法に受理された後であっても、公訴の提起があるまでは取り消すことができる。

エ 正しい

大判昭12.6.5は、他人を誤って犯人として指定した告訴について、これを有効であるとし、真犯人にその効力が及ぶとしている。判例の結論に賛成する学説は、理由として、告訴は、被害者が犯人を特定してその処罰を求めるところに重点があるのではなく、被害を受けた犯罪につき犯人の処罰を求めるところに重点があるということを挙げている。よって、被害者が犯人をXと指定して告訴したが、捜査の結果、犯人はYであることが判明した場合、その告訴はYに対して有効である。

オ 正しい

1個の犯罪事実の一部について告訴があった場合、原則としてその効力は犯罪事実の全部に及ぶとされている。この原則を告訴の客観的不可分の原則という。この原則については、主観的不可分(238条)と異なり、明文の規定がない。客観的不可分の原則には、例外が認められている。一罪として取り扱い、合一的に処断することが、親告罪を設けて告訴を訴訟条件とした趣旨を没却するような場合、客観的不可分の原則は適用されないとされる。その具体例として、数人の名誉を同一の文書で毀損した観念的競合の事案において、被害者中の一部の者だけが告訴した場合には、告訴した被害者に対する犯罪についてのみ告訴が有効であり、告訴をしない他の被害者に関する部分には告訴の効力は及ばないとされる。よって、1通の文書でA及びBの名誉が毀損された場合、Aがした告訴の効力は、Bに対する名誉毀損の事実には及ばない。

以上により、誤っている記述はアとウであり、したがって、正解は肢2となる。